

大法官講堂：  
中華民國憲法及政府（一）

第十九講  
平等權真諦

授課教師：湯德宗教授  
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示  
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

# 平等權真諦

## -- 合理的差別待遇

湯德宗

憲法有聲書

### 目 次

#### 壹、平等的概念

##### 一、雙面性／矛盾性（ambivalence）與相對性（relativity）

###### 1. 釋字 455〈翁岳生大法官協同意見書〉[3]：

「平等原則之旨趣在於禁止國家權力在無正當理由的情況下，對於相同類別之規範對象作不同之處理，故平等原則之本質，原就具有雙面性與相對性（ambivalent und relativ），嚴格而言並非各該「規範本身之違憲」，而是作為差別對待之兩組規範間的「關係」，或可稱為「規範關係之違憲」（verfassungswidrige Normenrelation）」。

###### 2. 釋字 455\_以「役別」為基礎所實施之差別待遇

###### 2.1 義務役 v. 志願役

僅後者之服役年資（於退休時）併計（為服務年資）

###### 2.2 先服（義務）役，嗣任公職 v. 先任公職，嗣服（義務）役

僅後者之服役年資（於退休時）併計（為服務年資）

##### 二、形式平等（formal equality）（≡ 假平等、絕對平等）v.

實質平等（substantive equality）（≡ 真平等、相對平等）

###### 1. *Plessy v. Ferguson*, 163 U.S. 537 (1896)

《對話憲法・憲法對話》2016

「隔離但平等」(“separate but equal”)

*Brown v. Board of Education*, 347 U.S. 483 (1954)

「隔離在本質上即為不平等」(“separate is inherently unequal”)

2. 「等者等之，不等者不等之」

3. 「實質平等」≠「等者等之，不等者不等之」

釋字 571〈林子儀大法官協同意見書〉n. 6

4. 行政程序法 §6：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇」

三、積極（矯枉／平權）措施（affirmative action），亦稱

「良性歧視」(benign discrimination)，或

「反向歧視」(reverse discrimination)，或

「積極歧視」(positive discrimination)

指為改正過往官方(“officially maintained”)刻意

(intentional) 施行之法律上的( *de jure* )差別待遇，而採取之反向歧視（矯枉過正）措施。

**Q** 有稱「優惠性差別待遇」者，是否貼切？

貳、「平等權」法律性質

Cf. 釋字 455〈翁岳生大法官協同意見書〉[3]

一、平等「權」= 平等「原則」？

「主觀權利」或「客觀規範」之立論差別？

釋字 727〈湯德宗大法官部分協同意見書〉

二、權利關係論 (Robert Alexy)

**Q** 「誰」能以之「對誰」主張「什麼」？

1. 權利主體 (= 「誰」能為主張)

19〈平等權真諦〉講綱

- 1.1 僅限於「中華民國人民」（國民）？
- 1.2 外國人、無國籍人亦得主張？
  - 釋字 560
2. 權利客體（≡ 主張「什麼」）
  - 2.1 空洞性（原本無一物）

平等權之內容原非特定，端視「何種權利」未受到「平等對待」而言
  - 2.2 包容性（得擴而充之）

§7 為「例示」規定，或「列舉」規定？  
差別待遇之分類基礎是否在 §7「例示」之列，影響審查基準（審查密度）？  
Cf. 釋字 727〈湯德宗大法官部分協同意見書〉

三、比較憲法例

- §7 (§§26-I-(7), 64-II, 129，增修 §§ 4-II, 10-VI)
- US
  - 14th Amend. (“No state shall deny to any person within its jurisdiction the **equal protection of the laws.**”)
- Q 何以美國未發展出基本權（間接）第三人效力理論？
- UK\_WC §19 (Equality)
  - 19.1 Everyone has the **right to recognition as a person** before the law.
  - 19.2 All person are entitled without any discrimination to the **equal protection of the law.**
  - 19.3 The equal protection of the law and the enjoyment of the rights and freedoms set out in this Bill of Rights shall

be secured ***without discrimination on any ground such as*** sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, homosexuality, disability, age, or other status. 

- ICCPR

§2.1

§3 (equality between the sexes) &

General Comment No. 4 (1981/07/30)

§4.1 (public emergency & derogation)

§20.2 (discrimination advocacy prohibited)

§26 

#### 四、效力（＝「對誰」主張）

Cf. 釋字 455 〈翁岳生大法官協同意見書〉[3]

##### 1. 拘束「立法權」之效力

###### 1.1 立法裁量（空間）之壓縮

 立法裁量空間與（各種）違憲審查基準之關係？

###### 1.2 立法本質之限制（禁止 “bill of attainder”）禁止針對「特定個人」立法（無論優惠或處罰）

##### 2. 拘束「行政權」之效力

###### 2.1 依法行政原則（TW\_APA §6）

###### 2.2 行政裁量之壓縮

###### 2.3 行政命令（法規命令）訂定之限制

##### 3. 拘束「司法權」之效力

###### 3.1 公平審判（fair trial）

###### 3.1.1 法庭組成應公正

3.1.2 法律適用應適切

(Ex. 案件起訴標準應一致，法令解釋應統一)

3.2 正當法律程序 訴訟當事人之地位應力求相當  
(武器對等原則)

4. 拘束國家私法行為之效力

- 釋字 457 (榮眷配耕農地＝使用借貸)
- 釋字 727 (軍眷配住眷舍＝使用借貸)

5. 間接拘束「第三人」(私人行為)之效力

5.1 國家保護義務

- 釋字 728 (祭祀公業條例 (96/12/12) §§ 4, 5)

5.2 限縮「私法自治」之立法

- 兩性工作平等法 (91/01/16) →  
性別工作平等法 (97/01/16)
- 性別平等教育法 (93/06/23)
- 性騷擾防治法 (95/01/18)
- 後天免疫缺乏症候群防治條例 (94/02/05)  
§6 之 1-I (感染人類免疫缺乏病毒者之人格與合法權益  
應受尊重及保障，不得予以歧視，拒絕其就學、就醫、  
就業或予其他不公平之待遇)  
§17 (違者處新台幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰)  
→ 人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例  
(96/07/11)  
§4-I (感染者之人格與合法權益應受尊重及保障，不得  
予以歧視，拒絕其就學、就醫、就業、安養、居住或予  
其他不公平之待遇)  
§23-II (違者，處新台幣三十萬元以上一百五十萬元以

《對話憲法・憲法對話》2016

下罰鍰)

- 身心障礙者權益保障法 (96/07/11)
    - §16 (禁止歧視)
    - §86-I (違者處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰),
    - §38 (進用比例保障)
  - 原住民族工作權保障法 (90/10/30)
    - §4 (公部門進用比例)
    - §5 (原住民地區公部門進用比例)
    - §12 (政府採購得標廠商進用比例)
    - §24 (違者處以代金)
- 釋字 719

參、平等保護的分析架構-- 美國模式

**Q** Is the government's classification at issue justified by a sufficient purpose?

一、存在「差別待遇」(平等權受「侵害」)?

**Q** What is the (government's) classification?

1. 顯然的差別待遇
2. 隱含的差別待遇
3. 誰受到差別待遇? 「個人」或「團體」?

**Q** 兩者審查基準有異?

**Q** 我憲法 §5 與 §7 有別?

二、應以何種審查基準?

**Q** What level of scrutiny should be applied?

1. 嚴格審查基準 (strict/ heightened scrutiny) [高標]

**Q** If the statute in question is *directly related to* a

**compelling/ overriding** governmental end/ interest→

If the restriction/discrimination is **narrowly tailored** (量身定作，恰如其份) and therefore is **the least restrictive means** (真正「限制最少之手段」)

2. 中度審查基準 (mid-level/ intermediate level review) [中標]

**Q** If the statute in question is **substantially related to a substantial/ significant/ important** governmental end/ interest

3. 合理審查基準 (mere rationality test; rational basis review) [低標]

**Q** If the statute in question is **rationally/ reasonably related to a legitimate/ permissible** governmental end/ interest

三、平等權違憲審查基準之演進 (二階→ 三階)

1. 合理審查基準 [低標]

1.1 事務領域

經濟、社會管制 (economic and social regulations)，但涉及「根本的基本權」 (fundamental rights) 或「可疑分類」 (suspect classifications) 者，除外

1.2 須為追求「合法」目的

- 「公共安全」 (public safety)
- 「公共健康」 (public health)
- 「公共道德」 (public morals)

...

1.3 不限於「真實之目的」 (actual purpose)，凡「可得想見之目的」 (conceivable purpose) 皆可

1.4 不審究是否「涵蓋過廣」 (over-inclusive) 或「涵蓋不足」 (under-inclusive)



《對話憲法・憲法對話》2016

## 2. 嚴格審查基準 [高標]

### 2.1 適用領域一

種族或出生國別之歧視 (discrimination based on race and national origin)

#### 2.1.1 理由

- 長時期之歧視易導致以刻板印象 (stereotypes) 或偏見 (prejudices) 作為分類之基礎
- 受歧視之群體殆為「政治參與」之 (相對) 弱者
- 種族與出生國別乃「與生俱來」之特徵，非當事人後天努力所能改變

#### 2.1.2 演進史

- *Dred Scott v. Sandford*, 60 U.S. 393 (1857)
- 13th Amend. (1865)
- 14th Amend. (1868)

#### 2.1.3 救濟

- 廢棄違憲之法律 (invalidating the discriminatory law)
- 廢棄違憲之法律，並頒禁制令 (invalidating the discriminatory law and fashion an injunction)
- 命採取積極 (矯枉／平權) 措施  
(例如命實施黑白合校政策 school desegregation)

### 2.2 適用領域二

積極 (矯枉／平權) 措施 (affirmative actions)

#### 2.2.1 得為「積極措施」之正當目的 (allowed purposes)

- Remedying past discrimination
- Enhancing diversity
- Providing role models for the minority group

- Enhancing services provided to minority communities

2.2.2 得採用之手段 (acceptable techniques/ means)

- Numerical set-aside (保留一定名額或數量)
- Using race as one factor in decision-making to help (將種族因素納入決策考量因素)
- 選區重劃

3. 中度審查基準 [中標]

3.1. 適用領域一：性別歧視 (gender classification)

3.1.1 理由

- Long history (歷史共業)
- 惟女性實際占社會人口之多數，且從未「孤立」於男性 (are not “isolated” from men)

3.1.2 Gender classification benefiting women based on role stereotypes generally not allowed

3.1.3 Gender classification benefiting women designed to remedy past discrimination and opportunities generally allowed

3.1.4 Gender classification benefiting women can be based on biological difference (生理差異) between men and women (如：僅婦女有產假)

3.2 適用領域二：對非婚生子女之歧視

3.2.1 理由

- Long history
- Yet non-marital children (illegitimacy) are innocent as it's immutable

肆、大法官平等權指標解釋總覽

一、男女（性別）平等

- 釋字 365（父權優先條款，合憲？）
- 釋字 457（退輔會農場場員死亡後，房舍土地限由男性遺產繼承之規定，合憲？）

*Cf.* 釋字 410, 452

二、宗教平等

- 釋字 490（國家不許成年男子以宗教信仰為由，豁免服兵役之義務，違憲？）

*Cf.* 釋字 460, 573

三、種族平等（racial or ethnic origin）

§§ 5, 7、增修 § 10-XI & XII

- 釋字 719（對原住民族之積極平權措施，合憲？）

四、階級平等

世襲之階級於我國早已消失，茲所謂「階級」當指各種社會性區分（social distinctions）

1. 出身／原籍平等（social or national origin）

- 釋字 618（大陸地區人民未在台設籍滿 10 年，不得擔任公務員，合憲？）

2. 社會地位（social status）平等

- 釋字 354（軍官 v. 士官）
- 釋字 455（志願役 v. 義務役）
- 釋字 596（勞工 v. 公務人員）
- 釋字 614（公營事業人員 v. 其他公務員）
- 釋字 647（已婚 v. 未婚）&

釋字 696（夫妻合併申報所得稅，較之單獨計算稅額，增加稅負部分，合憲？）

3. 財富（wealth discrimination）

- 釋字 468（無政黨推薦之人須繳交保證金，始得尋求連署以成為總統候選人之規定，違憲？）
- 釋字 701（身心失能無力自理生活而需長期照護者，其醫療費限以付予所得稅法所定醫療院所者，始得列舉扣除之規定，合憲？）

4. 學歷

- 釋字 290（各級民代候選人之學、經歷規定，合憲？）

五、黨派平等

- 釋字 340（政黨推薦之候選人得減半繳納參選保證金之規定，合憲？）

六、其他平等

1. 殘障（disability）

- 釋字 626（色盲不得報考警大研究所之規定，合憲？）
- 釋字 649（非視障者不得從事按摩業之規定，違憲？）

2. 性傾向（sexual orientation）

- 釋字 617（同性戀書刊應受平等保護？）

3. 年齡（age discrimination）

- 釋字 623（限制傳布以兒童、少年性交易為內容，或促使其為性交易為內容之訊息之規定，合憲？）
- 釋字 694（限扶養 20 歲以下或 60 歲以上之無謀生能力人，始得申報扣除額之規定，合憲？）

4. 國籍（alienage classification）

- 釋字 560（外國人眷屬於國外死亡時，勞保被保險人

《對話憲法・憲法對話》2016

不得請領喪葬津貼之規定，違憲？)

Cf. 釋字 438

5. 語言 (language)

6. 膚色 (color)

7. 意見 (political or other opinion)

- 釋字 727 (對不同意改建之原眷戶，得註銷其眷舍居住憑證及原眷戶權益之規定，合憲？)

【學思策問】

Q 「平等權」與「自由權」競合時，違憲審查機關應如何審查？

Q 關於「積極 (矯往／平權) 措施」，釋憲機關應以哪種基準審查其是否合憲？

【進階閱讀】法治斌，〈司法審查中之平等權：建構雙重基準之研究〉，《國家科學委員會研究彙刊：人文及社會科學》，第 6 卷 1 期，頁 35～50 (民 85 年 1 月)。

Michael J. Perry, *Modern Equal Protection: A Conceptualization and Appraisal*, 79 COLUM. L. REV. 1024 (1979).

【課後習作】

釋字 618 解釋認為「限制大陸地區人民未在台設籍滿 10 年者，不得擔任公務員」之規定合憲，主要理由為何？

# 版權聲明

| 頁碼      | 作品                                                                                                                                                                                | 版權標示                                                                                | 作者／來源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119-120 | 19.1 Everyone has the right to recognition as a person before the law.....association with a national minority, property, birth, homosexuality, disability, age, or other status. |    | The Institute for Public Policy Research, 《The Constitution of the United Kingdom》P55-P56<br>( <a href="http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2014/01/the-constitution-of-the-united-kingdom_1991-2014_1420.pdf?noredirect=1">http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2014/01/the-constitution-of-the-united-kingdom_1991-2014_1420.pdf?noredirect=1</a> )<br>瀏覽日期：2016/10/6，<br>本作品依據著作權法第46、52、65 條合理使用。 |
| 120     | 1.1 Protocol 4 §2: 凡合法入境者，皆應享有自由遷徙及自由選擇住居之權.....驅逐外國人出境之正當程序<br>(procedural safeguards relating to expulsion of aliens)                                                           |  | 《International Covenant on Civil and Political Rights》<br>本作品屬公共領域。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |